Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**063418N14**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	63418	**Fecha emisión**	18-08-2014		
Orígenes	MUN				

Referencias

181078/2014, 195964/2014, 201981/2014, 207297/2014

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

MSEV

Destinatarios

Alcalde de la Municipalidad de La Florida

Texto

No procede el otorgamiento de la concesión del servicio municipal de recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de la celebración de un contrato de transacción; no se ajustan a derecho las sucesivas contrataciones directas sobre la materia por parte de la Municipalidad de La Florida, la que debe regularizar la situación; y no se observan irregularidades en las actuaciones del director de control y de concejales que se indican.

Acción

Aplica dictamen 34913/2014 Aplica dictamen 55225/2011 Aplica dictamen 10546/2009 Aplica dictamen 21425/2014 Aplica dictamen 15700/2012 Aplica dictamen 84879/2013 Aplica dictamen 6643/2002 Aplica dictamen 70465/2012

Fuentes Legales

ley 10336 art/6 inc/3, ley 18695 art/66 inc/2, ley 18695 art/8 inc/4, ley 18695 art/8 inc/5, ley 18695 art/8 inc/6, pol art/6, pol art/7,
ley 18575 art/2, ley 18695 art/65 lt/h, ley 18575 art/3 inc/2,
ley 18695 art/79 lt/h, ley 18695 art/87, ley 20285 art/primero art/10, ley 18695 art/29 lt/d, ley 18695 art/79 lt/I, ley 18695 art/29 inc/fin,
ley 18695 art/81 inc/1, ley 18695 art/79 lt/b, ley 18695 art/51

Descriptores

MUN, concesión servicio recolección de basura, contrato de transacción, trato directo, probidad administrativa

Texto completo

N° 63.418 Fecha: 18-VIII-2014

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Reinaldo Rosales Méndez, concejal de la Municipalidad de La Florida, exponiendo ciertas irregularidades en que habría incurrido esa entidad edilicia, según estima, relacionadas con diversas contrataciones del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios y con la aprobación del contrato de transacción que aquella pretende celebrar con la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., requiriendo que se emita un pronunciamiento específicamente respecto de la procedencia de otorgar la concesión del aludido servicio a través de una transacción; del quórum con que esta habría sido acordada por el órgano colegiado; de la pertinencia de someter ese asunto a votación dos veces consecutivas; y de la demora de la autoridad edilicia en convocar a procesos licitatorios en la materia, reclamando, por último, la falta de entrega, por parte del municipio, de las copias de las transcripciones completas de las sesiones de concejo que indica, habiendo sido debidamente demandadas.

Por su parte, el alcalde del citado municipio pide que se determine si se ajusta a derecho que el director de control de esa entidad edilicia haya intervenido en las sesiones del concejo municipal en que se discutió y aprobó la anotada transacción, atendidas las razones que expone, así como si ha procedido el actuar de los concejales que señala, quienes, al abstenerse de emitir su

pronunciamiento en las votaciones en que se ha tratado la materia, habrían obstaculizado el funcionamiento de esa entidad municipal. Consulta, asimismo, cuáles serían las consecuencias que sus actuaciones producirían en términos de responsabilidad pecuniaria y administrativa, y requiere, finalmente, que se instruya un procedimiento sumarial en contra del mencionado funcionario municipal por los hechos indicados.

En cuanto a lo planteado por el concejal recurrente, expresa esa autoridad comunal, en síntesis, que la transacción de que se trata tiene por objeto velar por el patrimonio municipal, atendida la eventualidad de que la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. demande a la entidad edilicia por indemnización de perjuicios; que dicho contrato debía aprobarse con mayoría absoluta de los votos de concejales, toda vez que para el otorgamiento de concesiones no se exige un quórum distinto; que el asunto se sometió una segunda vez a votación por cuanto el valor de la prestación del servicio fue recalculado; y que las sucesivas contrataciones directas se deben, por una parte, a que la Fiscalía Nacional Económica observó en diversas ocasiones las bases de licitación de esa clase de procesos y, por otra, al rechazo de la propuesta de adjudicación de la licitación efectuada en el año 2012.

Requerido el director de control de la Municipalidad de La Florida, señor Arturo Molina Zamora, este señala, en lo que interesa, que las opiniones que vertió en las antes aludidas sesiones de concejo, fueron en consideración a los antecedentes que él mismo había obtenido sobre el asunto tratado, y que -a su juicio- la transacción en comento es ilegal, por cuanto no procede que dentro de las prestaciones recíprocas que esta debe contener, se contemple la celebración de un contrato de concesión.

A su vez, don Eugenio González Alarcón, en representación de la referida empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. solicita un pronunciamiento que determine si procede que la municipalidad considere en el cálculo del monto de la concesión del servicio que interesa -cuyo otorgamiento se pretende hacer efectivo a través de la celebración del contrato de transacción antes indicado-, un reajuste conforme a la variación que ha experimentado el precio del dólar en relación al mes de diciembre de 2012, época en que se rechazó su oferta en el marco de la licitación que señala, ante lo cual el municipio expresa que una adecuación de esa naturaleza no tendría justificación.

Por último, los concejales de la anotada entidad edilicia, señores David Peralta Castro y Claudio Arredondo Medina, manifiestan que el alcalde no ha acatado lo dispuesto en el dictamen N° 21.425, de 2014, de este origen -a través del cual se observaron las sucesivas contrataciones directas del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la comuna y se ordenó la instrucción de un procedimiento disciplinario al efecto-, denunciando, además, que el municipio habría utilizado el mismo mecanismo respecto de numerosos contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, acompañando antecedentes que darían cuenta de ello.

Como cuestión previa, y a fin de entender el contexto de las presentaciones de la especie, es necesario efectuar una breve relación de los hechos más relevantes que han dado origen a las actuaciones por las que se consulta.

En el mes de julio de 2012, el municipio convocó a una licitación pública para la concesión del servicio en comento, a cuyo término se propuso adjudicarla a la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., moción que fue rechazada por el concejo municipal, en sesión celebrada el 5 de diciembre de la citada anualidad, declarándose desierto el procedimiento a través del decreto alcaldicio N° 4.760, de fecha 6 del mismo mes y año.

En atención a lo anterior, la aludida empresa interpuso una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública en contra de la decisión del municipio, la que fue fallada mediante sentencia de 31 de enero de 2014, declarando ilegal tanto el acuerdo del concejo N° 148, de 2012, sobre la materia, como el anotado decreto N° 4.760, del mismo año, sin perjuicio de los derechos de aquella compañía para reclamar las indemnizaciones que estimare procedentes. En contra de ese pronunciamiento jurisdiccional, la entidad edilicia dedujo un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya resolución se encuentra pendiente.

En este contexto, el alcalde de la Municipalidad de La Florida sometió al acuerdo del órgano colegiado, con fecha 2 de abril de 2014, un proyecto de transacción con Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., en virtud del cual, en lo que interesa, la entidad pública contrata los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios con esa empresa, por el monto de $128.286.740 mensuales, propuesta que fue aprobada por el concejo por mayoría absoluta de sus integrantes.

Posteriormente, en sesión celebrada el día 5 del mismo mes y año antes citados, se sometió nuevamente a votación el proyecto de transacción, pero esta vez considerando como valor mensual de la prestación de servicios el total de $126.075.131, aprobándose aquel por el mismo quórum precedentemente indicado. En ambas ocasiones, el director de control fue requerido a fin de manifestar su opinión sobre el particular -actuación cuestionada por la máxima autoridad comunal-.

Luego, con fecha 8 de abril de la presente anualidad, ingresó a la Dirección de Control el proyecto de decreto que aprueba la transacción en comento, el cual fue devuelto sin visar, por estimarse ilegal.

En relación con la materia, es necesario precisar, en primer término, que atendida la existencia de la mencionada sentencia del Tribunal de Contratación Pública, que declaró la ilegalidad del acuerdo del concejo N° 148, de 2012, y del decreto alcaldicio N° 4.760, del mismo año, este Organismo de Control debe abstenerse de pronunciarse acerca de tales actuaciones municipales, como también sobre la forma de dar cumplimiento a lo fallado por dicho órgano jurisdiccional, en específico, en lo que se refiere a determinar si procede retrotraer la licitación de que se trata hasta la etapa procedimental cuestionada, ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General.

Puntualizado lo anterior, sin que importe emitir una opinión respecto del asunto sometido al conocimiento del tribunal precedentemente aludido, y solo con la finalidad de aclarar a la entidad edilicia de la especie la legalidad de una actuación municipal, cabe referirse a la procedencia del otorgamiento de una concesión de servicios a través de la suscripción de un contrato de transacción.

El inciso segundo del artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios por las municipalidades -cuyo es el caso- se ajustará a las normas de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus reglamentos, salvo lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° del primer texto legal citado, los que serán aplicables en todo caso.

A su vez, el inciso cuarto del mencionado artículo 8° señala, en lo pertinente, que la celebración de dicha clase de convenios se hará previa licitación pública, en el caso que el total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario sea superior a cien unidades tributarias mensuales. Los incisos quinto y sexto siguientes establecen las condiciones en las cuales procede recurrir a la licitación privada o a la contratación directa.

Por su parte, es necesario tener presente lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el sentido que los órganos del Estado, entre los cuales se comprenden los municipios, deben ajustar su proceder al principio de juridicidad, sin que puedan actuar al margen de ese marco ni aun a pretexto de la concurrencia de circunstancias extraordinarias o de razones de eficiencia (aplica criterio contenido en el dictamen N° 34.913, de 2014, entre otros).

De las normas anotadas, es dable colegir, entonces, que para entregar a un tercero la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, el legislador ha contemplado expresamente un procedimiento al efecto, el cual, en cumplimiento del principio de juridicidad antes aludido, debe ser observado por parte de la entidad licitante.

Pues bien, en la especie, en lo que interesa, la autoridad edilicia pretende, con el acuerdo del concejo, celebrar un contrato de transacción con la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., advirtiéndose del proyecto de la referida convención -que ha acompañado el propio municipio-, específicamente de su cláusula tercera, que a través de dicho convenio se adjudica a la mencionada compañía la "Concesión de Servicios de Recolección de Residuos Domiciliarios, Recolección Diferenciada Zona Norte y Barrido, Limpieza de Calles en Sector Centro de la Comuna de La Florida 2013-2018", sin que ella derive de manera directa de un procedimiento licitatorio convocado previamente.

Si bien aparece de los antecedentes tenidos a la vista que la mencionada empresa es aquella que fue propuesta por el alcalde al concejo para que le fuera otorgada la concesión en comento, en el marco de la licitación pública convocada sobre la materia en el año 2012, antes referida, no es posible entender que la adjudicación que se contiene en la transacción en análisis sea el resultado de ese procedimiento concursal.

Lo anterior, toda vez que dicho proceso fue declarado desierto mediante el citado decreto N° 4.760, de 2012, sin que se desprenda de los términos del contrato de la especie que aquella propuesta sea el antecedente directo de la adjudicación que se intenta realizar, sino que, por el contrario, el fundamento concreto de esta es la propia transacción y, por otra parte, cabe observar que, en todo caso, la misma no se ha ceñido a los términos de las bases administrativas correspondientes, desde el momento que contempla un incremento del valor mensual del contrato derivado de circunstancias acaecidas el año 2013.

Luego, atendido lo ya expuesto en el sentido que el otorgamiento de una concesión como la de la especie debe producirse, en principio, en el marco de un procedimiento de licitación pública, y que de acuerdo a los antecedentes antes expuestos, en la situación en análisis no se dio cumplimiento a esa formalidad, no cabe sino entender que lo que pretende la entidad edilicia es entregar la prestación del servicio en comento a una empresa a través de una contratación directa, sin que concurran los requisitos legales que permitan la utilización de dicho mecanismo.

Ahora bien, el hecho de que la adjudicación de que se trata se encuentre comprendida -a modo de prestación recíproca- en un contrato de transacción, y que este haya sido aprobado por el concejo municipal con el quórum legal requerido al efecto, como señala el alcalde recurrente, no modifica lo concluido precedentemente.

Al respecto, es necesario indicar que según lo dispuesto en el artículo 65, letra h), de la ley N° 18.695, las entidades edilicias cuentan con atribuciones expresas para transigir judicial y extrajudicialmente, requiriendo la máxima autoridad comunal al efecto el acuerdo del órgano colegiado, precisando la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Fiscalización contenida en el dictamen N° 55.225, de 2011, entre otros, que las convenciones que se celebren en esta materia suponen, necesariamente, la existencia de un derecho dudoso, actualmente controvertido o susceptible de serlo, y la presencia de mutuas concesiones y sacrificios recíprocos entre las partes, lo cual tampoco concurre en la especie.

Del mismo modo, el citado pronunciamiento ha indicado que la suscripción de contratos de transacción debe tender al cumplimiento de las finalidades propias del servicio y no puede abarcar materias regladas por la ley, en conformidad al antes referido principio de juridicidad.

Así, si el otorgamiento de una concesión para la prestación de un servicio municipal supone la realización de un procedimiento específico previsto por el legislador al efecto, según ya se analizó, no puede la entidad edilicia comprometerse a entregar el mismo a un tercero a través de una transacción como la que, en la especie, intenta celebrar la Municipalidad de La Florida con la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., toda vez que ello supone necesariamente, como antes se señalara, la omisión del cumplimiento de un mandato legal, cuestión que resulta inadmisible.

En consecuencia, atendidas las consideraciones anotadas, no cabe sino concluir que en la especie no resulta procedente que la Municipalidad de La Florida otorgue una concesión para la prestación del servicio de recolección

de residuos sólidos domiciliarios a través del contrato de transacción a que se ha hecho alusión, por tratarse de un procedimiento ajeno al que contempla al efecto el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, en lo que respecta al requerimiento del concejal recurrente en orden a que se precise el quórum con que debía ser aprobada la transacción en comento, considerando que esta comprendía la entrega en concesión de un servicio municipal por un plazo que excede el actual período alcaldicio, cumple manifestar que, atendido lo expuesto precedentemente en cuanto a la ilegalidad del otorgamiento de aquella mediante el mecanismo que pretende el municipio, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento sobre el particular.

A su vez, en cuanto a la procedencia de haber sometido al conocimiento del concejo municipal dos veces consecutivas un mismo asunto, esto es, la aprobación del contrato en comento, cumple anotar que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control contenida en el dictamen N° 10.546, de 2009, ha manifestado que los acuerdos que adopta ese órgano pluripersonal en las materias que, con arreglo al artículo 65 de la ley N° 18.695, somete a su consideración la autoridad edilicia -entre las cuales se contempla la transacción judicial y extrajudicial-, resultan vinculantes para esta última, pudiendo ser solamente revertidos a través de una nueva iniciativa del alcalde que logre la conformidad de ese cuerpo colegiado en un sentido distinto.

De lo anterior, se desprende que no existe inconveniente en que un asunto respecto del cual el concejo se ha pronunciado favorablemente, sea nuevamente sometido a su conocimiento, a instancias de la máxima autoridad comunal, a fin de revertir o modificar el correspondiente acuerdo.

En lo concerniente al cuestionamiento que efectúan los concejales recurrentes por la demora en que ha incurrido el alcalde en la convocatoria de diversos procedimientos concursales para la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la comuna, lo que ha derivado en sucesivas contrataciones directas de ese servicio, cabe recordar que mediante el dictamen N° 21.425, del presente año, esta Contraloría General se refirió a dicha materia.

El citado pronunciamiento concluyó, en síntesis, que las actuaciones del municipio en relación con los convenios celebrados sobre el particular no se ciñeron a la normativa pertinente, toda vez que entre los años 2011 y 2013 la contratación directa se transformó en una práctica reiterada; que sin perjuicio de tenerse en consideración el principio de continuidad del servicio y la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, el municipio debía adoptar los resguardos necesarios a fin de garantizar que los llamados a licitación se efectuaran con la suficiente antelación para evitar que se produzcan inconvenientes como los verificados en dicha oportunidad; y que se debían investigar las responsabilidades administrativas comprometidas en tales hechos, teniendo presente que el omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley lo dispone, constituye una conducta que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa.

Pues bien, como puede advertirse de los antecedentes acompañados por los concejales recurrentes y lo manifestado por el propio municipio, este efectuó, con posterioridad al dictamen en comento, en el mes de junio del presente año, dos nuevas contrataciones directas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la comuna con las empresas Dimensión S.A. y Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., cada una por el plazo de tres meses renovables, en atención, según expresa el alcalde, a la dificultad de llevar a cabo la concesión que se pretende otorgar a través de la transacción examinada.

Al respecto, cumple reiterar las observaciones contenidas en el dictamen antes señalado, en cuanto a la improcedencia de efectuar contrataciones directas sobre la materia, sin que resulten admisibles las argumentaciones de la autoridad edilicia, en orden a que dicho proceder ha obedecido a la imposibilidad de llevar a cabo la transacción de que se trata, atendida la ilegalidad de dicho mecanismo, tal como ya se analizó.

Por lo demás, es necesario tener en consideración que en el mes de julio de 2013 el municipio convocó a un proceso licitatorio para la “Concesión de servicios de residuos en papeleros de 50 lts., zona norte y sur, y barrido-

aspirado mecanizado calles de la comuna de La Florida 2014-2019", el cual fue declarado desierto a través del decreto alcaldicio N° 678, de 26 de febrero de 2014, sin que conste que con posterioridad se convocara nuevamente a otra propuesta pública, no obstante haber transcurrido un plazo suficiente para ello, debiendo hacerse presente que el hecho de que en el intertanto se haya notificado al municipio la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, no puede constituir un impedimento para que la entidad edilicia desatienda el cumplimiento de sus deberes.

Cabe agregar, en relación al último procedimiento de licitación fallido -cuestionado por el concejal señor Rosales Méndez por no solicitarse la opinión al órgano colegiado para declararlo desierto, y porque se habría tratado de una propuesta que el municipio no estaba en condiciones de financiar-, que según se advierte del citado decreto alcaldicio N° 678, de 2014, el fundamento de ello fue que los dos únicos oferentes propusieron precios excesivamente altos en relación al monto total estimado por el municipio, superando el presupuesto referencial en un 37,29% y 24,39% cada uno.

Sobre este punto, es dable manifestar a esa máxima autoridad comunal que el municipio, al efectuar contrataciones, debe procurar que se ajusten a su disponibilidad presupuestaria, observando los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, debiendo sus autoridades y funcionarios velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, de manera tal que en lo sucesivo debe evitar efectuar procesos de licitación cuyas exigencias la entidad edilicia no se encuentre en condiciones de solventar.

En este contexto, y atendida especialmente la circunstancia de que desde el año 2011 esa entidad edilicia ha utilizado el mecanismo de contratación directa para prestar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios -lo que si bien pudo justificarse excepcional y transitoriamente por razones de índole sanitario y a fin de dar continuidad a la prestación de ese servicio y de respetar situaciones jurídicas consolidadas-, cuya prolongación en el tiempo importa una contravención del ordenamiento jurídico, el alcalde de la Municipalidad de La Florida deberá, a la brevedad, adoptar las medidas que resulten pertinentes con el objeto de convocar a una propuesta pública sobre la materia y otorgar la pertinente concesión conforme a derecho.

Respecto del procedimiento disciplinario que se ordenó instruir al municipio a través del dictamen N° 21.425, de 2014, cabe señalar que en su informe la entidad edilicia expresa que aquel fue dispuesto por el decreto N° 1.478, de 2014, y sobreseído a través del decreto N° 2.345, del mismo año. Sin embargo, revisado el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, no consta que ese último instrumento haya sido remitido a esta Contraloría General para el correspondiente trámite de registro, en conformidad con el oficio circular N° 15.700, de 2012, de este origen, motivo por el cual la autoridad alcaldicia debe dar cumplimiento a dicha obligación.

Por último, el concejal señor Rosales Méndez reclama por el hecho de que, habiendo sido debidamente requeridas las copias de las transcripciones completas de las sesiones de concejo que indica, estas no le fueron entregadas.

Si bien el municipio no se ha referido específicamente en relación a tal materia, cumple hacer presente a esa autoridad comunal que en conformidad con lo establecido en los artículos 79, letra h), y 87 de la ley N° 18.695, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 84.879, de 2013, ha precisado que existen dos mecanismos para que los concejales individualmente considerados soliciten información, uno en virtud del cual el respectivo requerimiento al alcalde debe formularse por intermedio del concejo; y otro, por el que la petición puede ejercerse directamente ante la autoridad edilicia, sin intervención de ese cuerpo colegiado, pero con las limitaciones que en tal precepto se señalan.

Del mismo modo, según lo establecido en el artículo 10 de la ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, un concejal tiene derecho, al igual que cualquier persona, a requerir directamente, a título individual, la información que necesite con arreglo a lo dispuesto en la antedicha ley, salvo los casos de excepción que contempla el ordenamiento jurídico.

En atención a lo expresado, es dable manifestar que la máxima autoridad comunal se encuentra en la obligación de atender las solicitudes de información que le sean debidamente formuladas, en especial, por los concejales.

A continuación, cumple referirse a los cuestionamientos realizados por el alcalde de la Municipalidad de La Florida en su presentación, respecto de las actuaciones tanto del director de control, al oponerse a la celebración del contrato de transacción antes analizado, como de los concejales que no concurrieron con su voto a la aprobación de la adjudicación de la licitación realizada en el año 2012 a la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., ni se manifestaron en relación al contrato de transacción, quienes a su juicio, habrían obstaculizado el funcionamiento de la entidad edilicia.

En cuanto al mencionado funcionario municipal, se puede observar de los antecedentes acompañados, específicamente de las actas de las sesiones de concejo realizadas los días 2 y 5 de abril de 2014, que este intervino en dichas reuniones a requerimiento de determinados concejales, manifestando su opinión sobre la legalidad del proyecto de transacción que en esas oportunidades se pretendía someter a consideración del órgano colegiado.

Al respecto, cabe anotar que el artículo 29, letra d), de la ley N° 18.695, le otorga a la unidad de control municipal, la función de colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras.

En conformidad con lo anterior, la letra l) del artículo 79 del citado texto legal, establece que en el ejercicio de su función fiscalizadora, el aludido órgano colegiado, con el acuerdo de, al menos, un tercio de sus miembros, podrá citar a cualquier director municipal para que asista a sesiones del concejo con el objeto de formularle preguntas y requerir información en relación con materias propias de su unidad.

Ahora bien, en la especie, el señor Molina Zamora concurrió a las mencionadas sesiones a petición de ciertos concejales, emitiendo su opinión acerca de la legalidad y procedencia de la celebración del contrato de transacción respectivo, de lo cual no es posible advertir que haya infringido el principio de probidad administrativa -como lo ha afirmado la máxima autoridad comunal-, toda vez que habría actuado en el cumplimiento de sus deberes funcionarios.

Ello, considerando, además, lo manifestado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General contenida en los dictámenes N°s. 6.643, de 2002, y 70.465, de 2012, en el sentido que esa clase de servidores directivos pueden emitir válidamente opiniones o sugerencias en el marco de los asuntos que se someten a su conocimiento, siempre y cuando aquellas estén vinculadas directamente con las funciones que el legislador les ha conferido, lo que aconteció en la situación analizada.

En relación con la solicitud de la autoridad alcaldicia para que se instruya un sumario administrativo en contra del señor Molina Zamora, por los hechos antes referidos, cumple indicar que el inciso final del artículo 29 de la ley N° 18.695, establece que en el caso de incumplimiento de sus funciones, y especialmente de la obligación señalada en el inciso primero del artículo 81, el sumario será instruido por esta Contraloría General, a solicitud del concejo.

Pues bien, en conformidad con lo anterior, corresponde rechazar la petición en comento, toda vez que tal solicitud debe emanar del órgano colegiado, debiendo agregarse que, en todo caso, no se han advertido irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones propias del anotado funcionario municipal.

A su vez, en lo concerniente al cuestionamiento efectuado a la actuación de los concejales que solicitaron la intervención del aludido director de control, cumple manifestar que según lo expresado anteriormente, no se observa inconveniente en que aquellos hayan demandado la presencia del señor Molina Zamora, a fin de que este aclarara sus dudas sobre la procedencia de la transacción que la autoridad alcaldicia sometió a su aprobación.

Luego, en cuanto al rechazo a la propuesta de adjudicación de la licitación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., en la sesión de concejo de 5 de diciembre de 2012, a cuyo respecto el alcalde solicita un pronunciamiento,

cumple señalar que este Organismo de Control no puede intervenir en la materia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, atendido que como ya se indicó, dicha materia se encuentra en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 244-2012.

En cuanto al hecho de no haberse pronunciado ciertos concejales en relación a la propuesta de contrato de transacción, la autoridad alcaldicia indica que ello constituye una obstaculización de la prestación del servicio en comento, agregando que una de las obligaciones de estos es manifestar su voluntad a través de sus votos.

Sobre este punto, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 79, letra b), de la ley N° 18.695, en orden a que al concejo le corresponde pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de ese texto legal, debiendo los concejales presentes en la respectiva votación expresar su voluntad, favorable o adversa en relación con las materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva.

Pues bien, revisadas las actas de las sesiones de concejo de fechas 2 y 5 de abril del presente año, en las cuales se sometió a votación la tantas veces aludida propuesta de transacción, es dable advertir que en la primera de ellas hubo dos concejales que se abstuvieron de emitir su parecer, en tanto que en la segunda, lo hicieron cuatro de los integrantes de ese órgano colegiado, todos quienes expresaron un motivo por el cual no manifestaron un pronunciamiento a favor o en contra de la correspondiente proposición, de lo cual quedó constancia en dichos registros.

En atención a lo anotado, es dable concluir que no se observa irregularidad en el actuar de los concejales cuestionados.

En otro orden de ideas, en lo referente a la petición de la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., en el sentido que se emita un pronunciamiento sobre la legalidad de que el precio de la prestación del servicio que se pretende contratar por medio de la transacción precedentemente analizada, se reajuste conforme a la variación que el precio del dólar ha experimentado desde el mes de diciembre de 2012, cabe recordar lo manifestado con anterioridad en torno a la improcedencia de otorgar una concesión de un servicio municipal a través de la suscripción de un contrato de transacción, debiendo indicar que, en todo caso, tratándose de controversias sobre el valor que debe pagar la autoridad administrativa por la prestación de un servicio, esta Contraloría se encuentra impedida de intervenir, por tratarse de un asunto de carácter litigioso, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336.

Finalmente, cumple informar que los antecedentes acompañados por los concejales señores Peralta Castro y Arredondo Medina, que darían cuenta de numerosas contrataciones directas de adquisición de bienes y prestación de servicios efectuadas por el municipio, serán remitidos a la Unidad Técnica de Control Externo de la División de Municipalidades de este Organismo de Control, a fin de que se pondere su incorporación en los futuros procesos de fiscalización.

En consecuencia, en atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de este informe, cumple manifestar que la Municipalidad de La Florida debe adoptar las medidas que sean pertinentes a fin de regularizar las actuaciones observadas, dando cabal cumplimiento a la normativa que rige los procedimientos de otorgamiento de concesiones municipales, reiterándose que el omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley lo dispone, constituye una conducta que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa y que puede dar lugar a responsabilidad administrativa del alcalde, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la ley N° 18.695, como asimismo, que debe remitir los antecedentes de la investigación sumarial sobreseída a través del decreto alcaldicio N° 2.345, de 2014, informando a este Organismo de Control de todo ello en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente oficio.

Transcríbase a los concejales señores Reinaldo Rosales Méndez, David Peralta Castro y Claudio Arredondo Medina, a la empresa Servitrans Servicio

de Limpieza Urbana S.A., al concejo municipal de La Florida, al señor Arturo Molina Zamora, y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Municipalidades de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República